

1047841-96.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Mario Chiuvite Júnior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 22ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... alegando, em suma, ter sido vítima de roubo de aparelho celular, sendo que, após poucos momentos após o furto, sua conta já houvera sido movimentada, com transferência de valores de significativa monta e obtenção de empréstimo bancário. Narra ter o meliante realizado duas transferências para a conta do Autor, junto ao segundo corréu, por meio do aplicativo instalado no aparelho: uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

22ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº 9º andar - sala 915, São Paulo-SP - cep 01501-900

1047841-96.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1047841-96.2022.8.26.0100

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Daniel Henriques Mansour

Requerido:

BANCO BRADESCO S/A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Chiuvite Júnior

Vistos.

Daniel Henriques Mansour ajuizou ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais contra BANCO BRADESCO S/A e Mercadopago.com Representações LTDA, alegando, em suma, ter sido vítima de roubo de aparelho celular, sendo que, após poucos momentos após o furto, sua conta já houvera sido movimentada, com transferência de valores de significativa monta e obtenção de empréstimo bancário. Narra ter o meliante realizado duas transferências para a conta do Autor, junto ao segundo corréu, por meio do aplicativo instalado no aparelho: uma no valor de R\$40.000,00 e outra no valor de R\$15.000,00, ambas no mesmo momento, sendo que, em ato contínuo, os respectivos valores foram transferidos em quantias diversas para contas de terceiros (vide comprovantes - docs. 5/15). Mais uma transferência no valor de R\$4.999,99 foi feita para conta de titularidade de Beatriz Mathias Gomes dos Santos (doc 16), tanto ela como todas outras pessoas totalmente desconhecidas do Autor. Além disso, como se vê dos inclusive extratos, foi solicitado e concedido pelo Banco réu empréstimo no valor R\$20.000 (vinte mil reais), lançado na conta e também transferido, totalizando a subtração indevida de sua conta, mais o empréstimo concedido, a quantia de R\$79.619,89 (considerada a devolução de R\$380,10 efetuada pelo segundo corréu). Requereu, pois, o autor a condenação dos Réus a ressarcirem, solidariamente, os valores transferidos indevidamente, mais juros e correção monetária, contados até a efetiva reparação, bem como para se declarar nulo o empréstimo fraudulentamente

concedido pelo primeiro corrêu, para que ele se abstenha definitivamente de exigir o pagamento de suas parcelas, e, ainda, para condenar ambos os réus a pagarem, a título de indenização por danos morais causados, o valor de R\$20.000,00. Pleito de tutela antecipada foi deferido, na forma da decisão proferida a fls. 55/57, para determinar que a parte ré, imediatamente, não proceda à cobrança das parcelas dos empréstimos mencionados na inicial, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00.

O réu Mercadopago.com contestou o pedido a fls. 94/128, em sede preliminar, arguindo inépcia da inicial, pois o Autor deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, considerando que a petição inicial não individualizou ou comprovou quais transações efetivamente foram intermediadas pelo contestante. No mérito, em suma, aduziu não terem sido apresentadas provas que justificassem a responsabilização civil do Corrêu Mercado Pago, inclusive, tal quanto o argumentado anteriormente, o Autor sequer esclareceu as razões pelas quais os serviços prestados apresentariam falha de segurança, sendo que possui robustos mecanismos de segurança. Ressalta que o Autor, por sua vez, somente comunicou o Corrêu sobre o furto no dia seguinte ao ocorrido. E, pela análise conjunta dos poucos documentos acostados aos autos, temos que as transferências recepcionadas na conta do Autor, junto ao Corrêu MERCADO PAGO, foram provenientes de conta de igual titularidade mantida junto ao Corrêu Banco Bradesco, impossibilitando o acionamento de qualquer alerta de transação suspeita. Destacou o rompimento do nexo de causalidade pelo furto ocorrido e ausência de comunicação tempestiva pelo autor, tratando-se de fortuito externo e de culpa exclusiva da vítima. Argumentou, ademais, a parte ré a ausência de dano moral. Alternativamente, requereu o reconhecimento da culpa concorrente do autor e sustentou que o valor de R\$ 4.999,99 não foi transferido à conta mantida junto ao contestante.

O réu Bradesco apresentou defesa a fls. 223/270, em sede preliminar, arguindo ilegitimidade passiva, porque a operação foi realizada, por meio de token e senha, havendo transferência para conta de mesma titularidade, bem como inépcia da inicial, por falta de documentos, porquanto o boletim de ocorrência foi apresentado de forma parcial. Aduziu a casa bancária ré tratar-se de litisconsórcio necessário, em relação à pessoa que recebeu transferência da conta da autora: Beatriz Mathias Gomes dos Santos e, alternativamente, pleiteou a respectiva denúncia da lide. No mérito, reiterou que as transações foram realizadas mediante utilização de senha de 4 dígitos e TOKEN de segurança e por meio eletrônico (celular/internet). Registra que a chave de segurança no celular é o meio mais seguro, a partir do momento em que a cada minuto gera senhas aleatórias com 6 números cada uma. Logo, somente com o celular devidamente habilitado é que se torna possível qualquer transação, juntamente com a senha pessoal da Parte Autora. A única conclusão a que se chega no presente caso é, se de fato não tenha sido a Parte Autora que realizou as transferências e compras questionadas, faltou ela com seu dever de guarda e zelo de sua senha pessoal, bem como com a guarda de seu celular, evitando o acesso de outras pessoas à sua chave de segurança, o que explicita a sua exposição, por ato próprio, a risco, assumindo, por decorrência, a possibilidade da prática de eventual evento danoso. Por tudo o que se expôs, verifica-se que não se pode alegar qualquer falha na prestação de serviços pelo Banco Réu, até porque não seria crível reconhecer qualquer alegação de fraude nas transações ocorridas, quando a Parte Autora, em momento algum, esclarece como supostamente terceiros poderiam ter acesso à sua senha pessoal e ao seu dispositivo de segurança constante do celular, única forma que lograriam ter sucesso em realizar as operações em comento. A realização de transações financeiras por terceira pessoa, mediante o uso do cartão da parte autora, somente seria possível se o terceiro estivesse na posse do cartão e tivesse ciência de seus dados pessoais e de sua senha. O usuário é responsável pela escolha, sigilo e guarda da senha e responde pelas operações realizadas, enquanto não comunica a instituição financeira em tempo hábil sobre o furto ou perda, de modo a viabilizar o seu bloqueio e impedir o correlato uso indevido. Deste modo, não se pode, no entender do contestante, portanto, deixar de reconhecer a culpa exclusiva da Parte Autora, ou ainda de terceiro, para a ocorrência dos fatos em tela, sendo essa excludente de qualquer responsabilidade do Banco Réu, nos termos

do artigo 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. Aduziu o réu que há duplicidade no pedido de danos materiais, pois os valores transferidos já incluem o empréstimo, restringindo-se o prejuízo a R\$ 40.000,00. Sustentou o contestante a ausência dos requisitos da sua responsabilidade civil, por falta de prova da existência de ato ilícito praticado pelo Banco Réu, dos supostos danos experimentados, do nexo de causalidade entre a conduta do Banco Réu e os danos sofridos. Alegou, ademais, a ausência de dano moral, tratando os fatos de simples dissabor; alternativamente, requereu o réu a fixação com moderação do montante da indenização, proporcionalmente ao grau de culpa e ao nível socioeconômico da parte autora, bem como em termos de razoabilidade e do bom senso, atendendo-se à realidade da vida e às peculiaridades do caso. Réplica apresentada a fls. 279/283 e 285/290.

É o Relatório.

Fundamento e Decido:

O feito comporta o julgamento antecipado por se referir à matéria de direito, dispensando dilação probatória nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, o pedido inaugural é PROCEDENTE.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que afirma a autora ter ocorrido movimentações financeiras indevidas em suas contas mantidas junto aos réus.

De início, a inicial se mostra apta a produzir seus efeitos jurídicos, encontrando-se formulada na forma do artigo 319 do Código de Processo Civil; ausente hipótese prevista no artigo 330 do CPC, encontrando-se, pois, presentes todos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Afasto a preliminar acerca da ilegitimidade arguida pela respectiva parte ré, pois houve movimentação em conta mantida na instituição financeira ré, sendo que eventual dever de indenizar diz respeito ao mérito da ação.

Não medra a alegação no réu, em relação à ausência do favorecido das transações no polo passivo da ação, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, não havendo qualquer óbice para o ajuizamento da ação apenas em face do Banco.

Outrossim, não prospera o pedido de denunciação da lide por não se tratar de hipótese descrita no art. 125 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

VOTO Nº 37256 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Golpe do Boleto Falso. Legitimidade passiva da instituição financeira configurada. Inadmissibilidade de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário ou de denunciação da lide ao terceiro fraudador. Falha de segurança na prestação do serviço bancário evidenciada. Terceiro fraudador que teve acesso a dados restritos, tal como o número do contrato e CPF do devedor. Abertura de conta fraudulenta e/ou emissão de boleto timbrado em nome do Grupo Santander, grupo do qual a Aymoré faz parte, como meio necessário para operacionalizar a fraude. Banco-apelante que argumentou ser possível identificar o terceiro fraudador, o que reforça a ocorrência da falha de segurança. Responsabilidade objetiva da instituição financeira caracterizada. Súmula 479 do STJ. Condenação do Banco-apelante à restituição dos valores dispendidos pelo Apelado em razão do golpe. Juros moratórios que incidem a partir da citação, por se tratar de relação jurídica contratual. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003529-90.2020.8.26.0266; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 16/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022) (grifei) Impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, impõe-se que seu exame seja realizado sob a lente do microsistema protetivo, instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, observando-se a vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor. Nesse sentido, afigura-se possível a inversão do ônus da prova, dada a evidente hipossuficiência do consumidor na hipótese (art. 6º, VIII do Código de Defesa do

Consumidor), cabendo ao réu o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

Segundo consta dos autos, restou incontroversa a ocorrência de movimentações indevidas na conta da autora e a defesa dos réus se baseia na alegação de utilização das senhas e token.

Nesta senda, cabia à parte ré a demonstração de que as operações descritas na presente lide foram realizadas de fato pela parte autora.

Impende destacar que a responsabilidade civil invocada no caso em testilha é de ordem objetiva, apenas podendo ser afastada quando houver prova efetiva de caso fortuito, força maior e/ou culpa exclusiva da vítima, à luz da Súmula 479 do STJ verbis: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Ação declaratória de nulidade de crediários automáticos, cumulada com o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de saques e transações indevidas em conta corrente - Responsabilidade solidária da empresa que fornece o caixa eletrônico 24 horas - Solidariedade estabelecida nos arts. 7.º, Parágrafo Único, 14 e 25, § 2.º, do Código do Consumidor - Inocorrência de cerceamento de defesa - Inversão do ônus da prova a favor do autor, art. 6.º, VIII, do aludido diploma - Possibilidade de fraude de cartão utilizado mediante chip e senha pessoal - Anulação dos crediários - Cabimento da devolução dos valores debitados da conta - Ausência de diligência habitual da instituição financeira - Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça - Ilícito configurado - Responsabilidade objetiva do ofensor perante o evento - Risco implícito às atividades - Reparação devida - Prejuízos presumidos pelos descontos indevidos na conta corrente do autor - Inexistência de pré-excludentes - Adequação do arbitramento em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática - Recurso do réu provido, em parte, provido o do autor. (Relator(a): César Peixoto; Comarca: Jacareí; Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 05/04/2017; Data de registro: 07/04/2017) (grifei)

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Saques e contratação de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora - Inadmissibilidade - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva da autora - Aplicação da teoria do risco profissional - Existência de "chip" no cartão que não afasta a responsabilidade do banco - Sistema de segurança falho - Restituição dos valores descontados da conta corrente - Indenização devida - Valor fixado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deve ser mantido - Recurso improvido." (Relator(a): J. B. Franco de Godoi; Comarca: São Joaquim da Barra; Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 13/01/2017; Data de registro: 13/01/2017)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferências bancárias não reconhecidas pelo titular da conta. Alegação de fraude. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Inexistente nulidade da r. sentença por falta de fundamentação. O Juízo não está adstrito às alegações da parte requerida. Regra do livre convencimento motivado. Cerceamento de Defesa inocorrente. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, o acolhimento da pretensão inicial. Precedentes. Inexistência de confissão ficta. Inteligência do art. 302, III, do CPC/73. Inversão do ônus da prova. Parte ré que não comprovou a realização das transferências pelo titular da conta. Conclusão do laudo pericial de que as operações não foram realizadas pelo computador da parte autora. Gravação telefônica juntada pela parte após a contestação. Contraditório respeitado e ausência de má-fé da parte apelada. Mitigação da regra prevista nos arts. 369 e 397 do CPC/73. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. Preposta da empresa autora que admitiu ter fornecido senha e número de 'token' a terceiro que se passou por funcionário do banco réu. Transferências realizadas por fraudadores em função de convênio para pagamento de salários, cuja contratação não foi comprovada pela instituição financeira. Peculiaridade das movimentações detectada pelo banco réu, que entrou em

contato com a parte autora para confirmar a legitimidade das operações. Ausência de bloqueio das operações suspeitas, agravando as consequências do ato ilícito. Relação de consumo. Aplicação do art.14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Falha na prestação de serviço. Culpa concorrente da parte autora. Inteligência do artigo 945 do Código Civil. Precedentes. Dano material consubstanciado no valor total transferido, cuja metade deverá ser devolvida à parte autora, deduzido o valor estornado. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé. Juros moratórios aplicados desde a citação, posto se tratar de responsabilidade civil contratual. Indenização por dano moral afastada. Parte autora que, além de concorrer, culposamente, para a existência do ato ilícito, não comprovou os alegados danos à personalidade. Ocorrência de dano moral que não se presume na hipótese. Alegada negativação do nome da consumidora que não restou provada. Contatos prévios com a parte contrária, com vistas a uma solução amigável do problema, que se constituem em mero aborrecimento. Parte autora que negou ter fornecido senha e número de 'token' a terceiros. Litigância de má-fé caracterizada. Deliberada alteração da verdade dos fatos com vistas a induzir o Juízo a erro. Multa de 1% do valor da causa aplicada. Ônus sucumbencial carreado integralmente à parte autora, conforme artigo 21, § único, do CPC/73. Recurso provido em parte, com determinação. (TJSP; Apelação 1008943-35.2014.8.26.0604; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 12/06/2017)

Cabe mencionar Carlos Roberto Gonçalves que “a responsabilidade objetiva funda-se, efetivamente, num princípio de equidade, existente desde o direito romano: aquele que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes (Ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi incommoda). Quem aufere os cômodos (lucros) deve suportar os incômodos (riscos)” (Comentários ao Código Civil, vol. 11, ed. Saraiva, 2003, p. 314).

Dessarte, a autora deverá ser restituída em relação aos valores das movimentações, compras e empréstimos realizados, afastando-se, por conseguinte, todos encargos decorrentes das operações descritas na inicial, tais como juros, encargos, tarifas sobre saldo devedor, seguros, etc.

Outrossim, irrelevante a alegação do réu Mercadopago, no sentido de que essa conta serviu apenas como meio de transferência de valores, considerando que ambas as instituições apresentaram falha de segurança permitindo que terceiros acessassem as contas da autora e as movimentassem livremente, de modo que os réus responderão integralmente e solidariamente por todos os danos, nos termos dos artigos 7º e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no que diz respeito ao dano moral, para sua configuração, como é cediço, o julgador deve ter por base a lógica razoável decorrente dos fatos que lhes são apresentados pelos demandantes, reputando dano apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação que, demonstrando-se anormais, venham a interferir, intensamente, no comportamento psicológico do indivíduo, acarretando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

Portanto, o dano moral resulta de evidente infração ao conteúdo de direitos integrantes da personalidade, conforme a principiologia jurídica adotada pelo artigo 5º, V e X da Constituição Federal.

Deve-se levar em consideração, para evitar situações que afrontam ao direito positivo pátrio, a existência de fatos que denotam a ocorrência de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, os quais estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

No caso em tela, os fatos descritos acarretaram à parte autora, indubitavelmente, sérios constrangimentos, além de meros aborrecimentos, segundo as regras regulares de experiência (artigo 375 do Código de Processo Civil), diante de ter sido submetida a uma situação grave de fraude e às suas consequências.

O dano moral deve ser quantificado, conforme sua intensidade, devendo a indenização ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo

adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Destarte, considerando os critérios acima mencionados, mormente a extensão do dano causado e a necessidade de se evitar a reiteração dos fatos em tela, fixo, a título de indenização pelos danos morais acarretados à parte autora, o valor de R\$ 5.000,00, sendo, pois, o mesmo suficiente para a reparação dos danos morais supradescritos, em observância aos mencionados princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, julgo o pedido inicial PROCEDENTE, resolvendo o mérito da causa, com espeque no disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela antecipada concedida a fls. 55/57 na forma legal e, em definitivo, a fim de condenar os réus a ressarcirem, solidariamente, todos valores transferidos indevidamente in casu, em desfavor da parte autora, mais juros e correção monetária contados até a efetiva reparação, bem como no sentido de declarar nulo o empréstimo fraudulentamente concedido pelo Banco réu Bradesco, para que ele se abstenha definitivamente de exigir o pagamento das parcelas em questão, inclusive, eventuais encargos decorrentes das operações descritas na inicial, tais como juros, encargos, tarifas, seguros, impostos, etc,; tais valores serão acrescidos de correção monetária, fixada pela tabela prática do Egrégio TJSP, e com juros de mora de um por cento ao mês, ambos desde a data do evento ocorrido nas contas da parte autora, nos termos respectivamente das súmulas 43 e 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do artigo 398 do Código Civil, bem como para condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, pela tabela prática do Egrégio TJSP, desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 do C. STJ), e com juros de mora de um por cento ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Sucumbentes, arcarão os réus com custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da condenação devidamente atualizado.

P.R.I.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA